



G7 Jurídico

Analistas
Direito Processual Penal – Nestor Tavora
Aula 08

MATERIAL DO PROFESSOR

PROVAS

Teoria geral da prova (arts. 155 ao 157, CPP)

1- Conceito: é tudo aquilo que é levado ao conhecimento do julgador com o objetivo de convencimento em face dos fatos deduzidos na demanda penal.

Obs.1. Destinatários:

- a) Destinatário DIRETO ou IMEDIATO- órgão julgador.
- b) Destinatário INDIRETO ou MEDIATO- as partes que atuam na demanda, já que, quanto melhor o manancial probatório, maior a probabilidade de pacificação social.

Obs.2. Enquadramento terminológico- de acordo com Guilherme Nucci, a prova pode ser entendida diante dos seguintes significados:

- a) Ato de provar (instrução probatória);
- b) O meio para provar- os instrumentos para a demonstração da verdade.
- c) O **resultado** obtido em face da análise do material probatório.

2- Natureza jurídica- a prova é enquadrada como DIREITO SUBJETIVO, intimamente ligado ao exercício da ação ou ao desenvolvimento da atividade defensiva.

3- Objeto:

3.1- Objeto DA prova- ele envolve os FATOS RELEVANTES ao julgamento da causa penal.

3.2- Objeto DE prova- ele engloba os fatos pertinentes á prestação jurisdicional. Logo, também poderemos identificar aquilo que prescinde de prova, vejamos:

a) Direito federal

Obs. O direito estadual, municipal, consuetudinário e estrangeiro demanda prova, em face da vigência e existência.

b) Fatos notórios ou verdade sabida: são aqueles de conhecimento de parcela significativa da população medianamente informada. Ex. Feriados nacionais.

Obs. No processo penal, os fatos incontroversos dependem de demonstração probatória.

c) Fatos axiomáticos ou intuitivos: são aqueles que se auto demonstram em face das próprias circunstâncias.

d) Presunção: é a observação de um fato que nos permite fazer uma conclusão em face do que normalmente acontece.

Obs. Classificação:

d.1) Presunção hominis: é aquela extrajurídica, diante do contexto social.

d.2) Presunção juris ou legal- é aquela positivada em lei como verdade, vejamos:

d.2.1) Presunção ABSOLUÇÃO (jure et de juris)- é aquela que inadmite prova em contrário. Ex. inimputabilidade dos menores de 18 anos.

d.2.2) Presunção legal RELATIVA (juris tantum)- ela tolera prova em sentido contrário, leia-se, inverte o ônus probatório.

e) Fatos inúteis- irrelevantes para a demanda penal.

4- Meios de prova:

4.1- Conceito: são as ferramentas ou instrumentos jurídicos empregados para produzir a prova e encaminhar ao conhecimento do julgador.

4.2- Classificação da prova em face da regulação (ou não) do meio

a) Prova NOMINADA- é aquela cujo meio de produção está devidamente regulado em lei. Ex. Arts 158 ao 250, CPP.

b) Prova INOMINADA- é aquela cujo meio de produção ainda não encontra disciplina normativa, não se confundindo com as provas ilícitas. Ex. Perícia para a identificação da voz por comparação.

ADVERTÊNCIA: podemos empregar provas nominadas e inominadas, inexistindo hierarquia entre elas.

4.3- Justificativa principiológica para a ampla utilização probatória

a) Princípio da liberdade na produção da prova- temos assegurada a ampla possibilidade de produção probatória, o que engloba provas nominadas e inominadas, inexistindo hierarquia normativa (Item VII da Exposição de Motivos do CPP; art. 93, IX, CF; art. 155, CPP).

b) Princípio da verdade real ou material- o juiz criminal não vai se conformar com especulações de verdade, já que o processo criminal deve reproduzir o que de fato ocorreu no momento da prática do delito.

Obs.1. Com tal valor, historicamente justificamos uma ampla iniciativa probatória do juiz, amparada da reformulação do art. 156 do CPP, promovida pela Lei 11.690/08.

Obs.2. Com o protagonismo judicial, tivemos uma ampla crítica por força da ofensa ao sistema acusatório, comprometendo a imparcialidade do julgador, que com o seu protagonismo passou a flertar com a inquisitorialidade.

Obs.3. Princípio da verdade processual/ verdade humanamente possível- como a verdade real é um dogma inalcançável, o processo deve respeitar as regras do jogo, com contraditório, ampla defesa, imparcialidade, paridade de armas e devido processo legal. Logo, ratificamos o sistema acusatório e o juiz não deve atuar como protagonista da prova.

Obs.4. Exegese do art. 3º-A do CPP:

o STF, em controle de constitucionalidade, firmou as seguintes teses:

- Adotamos o sistema acusatório;
- O juiz não poderá substituir a atuação DAS PARTES na produção probatória;
- O juiz, pontualmente, de limites da lei e forma SUPLEMENTAR, poderá determinar de ofício a produção de prova que interfere na solução de dúvida sobre questão relevante para o mérito da demanda penal.

4.4- Limitações à liberdade de produzir prova

4.4.1- Demonstração do estado civil das pessoas

I- Conceito: devemos atender ao contexto das exigências da legislação civil (art. 155, parágrafo único, CPP).

Obs. De acordo com a Súmula 74 do STJ, a demonstração da menoridade exige documentação idônea.

4.4.2- Vedação da prova ilícita (art. 5º, LVI, CF; art. 157, CPP)

I- Conceito:

a) Conceito DOUTRINÁRIO- para Ada Pellegrini, com ampla influência da doutrina francesa de Pietro Nuvolone, o gênero é a prova VEDADA ou PROIBIDA, do qual fazem parte as seguintes espécies:

a.1) Prova ILÍCITA- é aquela que viola o direito material, leia-se, o CP, a legislação penal especial ou os princípios constitucionais penais.

Conclusão: o prova ilícita não deve ser admitida no processo (art. 5º, LVI, CF). Se eventualmente a prova ilícita ingressar no processo, diante da declaração de ilicitude, deve ser desentranhada e inutilizada, na presença facultativa das partes (§ 3º, art. 157, CPP).

a.2) Prova ILEGÍTIMA- é aquela que viola o direito processual penal, leia-se, o CPP, a legislação processual especial ou os princípios constitucionais processuais.

Conclusão: diante da ilegitimidade da prova, é possível a declaração de nulidade, com a perspectiva de nova produção, se for possível.

b) Conceito LEGAL- art. 157 do CPP não encapou a dicotomia doutrinária, considerando como ilícita a prova que viola a norma, constitucional ou infraconstitucional, pouco importa se material ou processual.

II- Teorias sobre a utilização (ou não) da prova ilícita

a) Teoria da proporcionalidade/teoria da razoabilidade/teoria do sacrifício- na ponderação entre bens jurídicos relevantes, devemos dar prevalência ao de maior importância.

Conclusão: logo, a prova ilícita pode ser empregada em favor do imputado.

Obr.1. Prova ilícita em favor da acusação- segundo Fernando Capez, a prova ilícita pode ser utilizada em favor da acusação, notadamente no combate ao crime organizado, ressalvada a confissão mediante tortura (posição minoritária).

Obs.2. Há quem entenda que a proporcionalidade envolve a proibição de excessos, potencializando a preservação de direitos e garantias fundamentais.

Obs.3. Dentro da análise interpretativa da proporcionalidade, temos a proibição da proteção deficiente, ressaltando a preservação do bem jurídico tutelado.

Obs.4. A proporcionalidade surge na Alemanha do pós 2º guerra, sendo levada aos USA como razoabilidade, e trazida ao Brasil com precedentes do STF.

b) Teoria da exclusão da ilicitude da prova- segundo Afrânio Silva Jardim, as excludentes de ilicitude, notadamente o estado de necessidade e a legítima defesa, podem ser empregadas para justificar o comportamento de produção probatória.

Conclusão: logo, a prova produzida é VÁLIDA, podendo ser empregada pela defesa ou pela acusação.

c) Teoria dos frutos da árvore envenenada/ teoria dos fruits of the poisonous tree/ teoria da prova ilícita por derivação- uma prova derivada de outra ilícita está contaminada por desdobramento lógico.

Obs. A prova derivada FORMALMENTE pode ser perfeita. Logo, a contaminação é MATERIAL, já que ela deriva de uma prova ilícita.

Obs.2. O art. 5º, LVI, CF, não trata da prova derivada. A matéria, após a Lei 11.690/08, mereceu destaque no § 1º, art. 157, CPP.

d) Teoria da descoberta inevitável- a prova que deriva de uma ilícita não estará contaminada na hipótese em que ela inevitavelmente seria revelada por uma OUTRA FONTE AUTÔNOMA.

Obs. O origem é a Suprema Corte dos USA, tendo atual previsão na parte final do § 1º do art. 157, CPP.

e) Teoria da prova absolutamente independente (PAI): a existência de uma prova ilícita nos autos não necessariamente contamina o processo. Logo, existindo outras provas, ABSOLUTAMENTE INDEPENDENTES DA PROVA ILÍCITA, o processo será preservado.

Obs.1. Esta teoria tem inspiração na Suprema Corte dos USA, e atualmente é regulada no § 1º, segunda parte, do CPP.

Obs.2. As provas que independem da ilícita representam a base do processo criminal.

Obs.3. De acordo com o § 3º do art. 157 do CPP, a prova declarada como ilícita será desentranhada e destruída na presença facultativa das partes.

Obs.4. O § 5º do art. 157 do CPP foi reputado inconstitucional. Logo, o juiz que tem contato com a prova ilícita NÃO está impedido de julgar a causa.

Conclusão: nada impede que o juiz reconheça a sua incompatibilidade.

f) Teoria do nexu atenuado- caberia ao juiz avaliar o vetor qualitativo entre a prova ilícita e a prova derivada. Logo, se o nexu é frágil, pode ser desconsiderado, valorando-se a prova derivada.

Obs. Esta teoria não foi albergada com a reforma do CPP.

g) Teoria da boa-fé- quando a autoridade está de boa-fé na prospecção da prova, evitamos o reconhecimento da ilicitude, mesmo quando protocolos legais não sejam atendidos.

Obs.1. O STF já teve a oportunidade de afastar a aplicação da teoria da boa-fé, afinal, além do componente subjetivo, a lei e a CF devem ser respeitadas.

Obs.2. O STJ já aceitou a teoria da boa-fé em contexto de cumprimento de mandado diante de erro na execução por se tratar de casa geminada (STJ. HC 633.441).

Obs.3. Tal teoria não tem previsão no art. 157 do CPP.

5- Ônus da prova

5.1- Conceito: é a incumbência de demonstrar o que foi alegado, típica da atuação das partes (art. 156, CPP).

Obs. A parte se sujeita às consequências por eventual inação.

5.2- Classificação do ônus:

5.2.1- Ônus OBJETIVO- ele revela uma TÉCNICA DECISÓRIA pautada no princípio do “in dubio pro reo”.

5.2.2- Ônus SUBJETIVO

I- Conceito: ele caracteriza a incumbência de demonstração do que foi alegado, típica da atividade das PARTES.

II- Distribuição:

a) 1º posição- para a DOUTRINA MAJORITÁRIA, o ônus é assim repartido:

a.1) Ônus da ACUSAÇÃO:

- autoria;
- materialidade;
- nexos;
- dolo/culpa.

a.2) Ônus da DEFESA:

- excludentes de ilicitude;
- excludentes de culpabilidade;
- causas obstativas ou extintivas da punibilidade.

b) 2º posição- para Paulo Rangel, em posição minoritária, diante da presunção de inocência e do “in dubio pro reo”, o ônus é integralmente da acusação, afinal, se o MP não for integralmente exitoso em provar, cabe ao juiz absolver o imputado.

5.3- Iniciativa probatória do JUIZ